

1500304-78.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato dos Santos

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes.

Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado:

inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

1500304-78.2019.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500304-78.2019.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF DA SILVA NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Segue sentença.

Vistos etc.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de ALEF DA SILVA NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos: Consta da denúncia que volta das 12h50, na Avenida Itajobi, 10, Morada Pitoresca, nas imediações da Igreja Deus é Amor, da Igreja Pentecostal Glória Deus - Ministério Andando na Palavra, da Escola Municipal Maria Elce Martins Bertelle, da Escola Municipal de Educação Infantil Emellyne de Azevedo Aguiar e da Escola Municipal de Educação Básica Maria Gonçalves de Freitas Gonçalves, 1 neste município e comarca de Cajamar, o denunciado, qualificado a fls. 10 e 30/32, traria consigo e guardaria 8 porções de maconha (massa líquida: 14,16 gramas), 2 porções de cocaína (massa líquida: 0,63 grama) e 1 porção de crack (massa líquida: 0,15 grama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para comercialização e entrega a consumo (auto de exibição e apreensão a fls. 14/15 e laudos de constatação a fls. 18/26).

Em sede de plantão judiciário, a prisão em flagrante do denunciado foi substituída por liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (fls. 42/44).

A denúncia foi recebida em 15.03.2019 (fls. 79/80), o réu foi regularmente citado (fls. 104) e ofereceu defesa prévia (fls. 102/103).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 112/113, prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas testemunhas, enquanto o réu teve sua revelia declarada.

Em alegações finais (fls. 163/167), o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A Defesa (fls. 171/177), por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico para o descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, ainda, por benefícios no tocante à pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de ALEF DA SILVA NASCIMENTO pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A ação penal merece parcial procedência.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação da natureza tóxica (fls. 18/20, 21/23 e 24/26) e laudo pericial químico de entorpecente (fls. 154/156 e 157/159).

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado ALEF DA SILVA NASCIMENTO.

Inquirida, a testemunha Gilmar Campos Fonseca Bueno, guarda municipal, disse em juízo que, na data dos fatos, estava em patrulhamento pelo local, conhecido pela venda de drogas, quando avistou o denunciado que demonstrou nervosismo com a presença dos Agentes Públicos. Abordado, foi localizado em poder dele, no seu bolso traseiro, notas fracionadas de dinheiro. Indagado, ele admitiu a venda de entorpecentes pois passava por dificuldade financeira. Indagado sobre a localização da droga, ele informou que estava na roda do veículo Gol parado próximo a ele, cerca de 2 ou 3 metros, no máximo. Dirigiu-se então até o aludido veículo, onde foram localizados os entorpecentes. Ele estava parado no local no momento da abordagem. Não conhecia o acusado. Ele estava sozinho quando foi abordado. Havia uma creche a cerca de 5 metros para cima do local da abordagem.

A testemunha Giovani Carmelo Castellano, guarda municipal, estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas; que o acusado demonstrou nervosismo, o que gerou fundada suspeita; que o dinheiro apreendido o acusado disse que era da venda de droga; que o acusado indicou o local onde estavam os entorpecentes. Foram localizados cocaína, maconha e crack. Não se recorda ao certo da quantidade. Crê que era pouca quantidade. As drogas foram encontradas a 1 metro e meio ou 2 metros, aproximadamente, do local da abordagem, embaixo de um carro indicado pelo acusado. Não havia mais ninguém no local. Já havia avistado o denunciado no local algumas vezes, mas nunca tinha abordado ele antes. Tinha uma escola a 150 metros do local.

O acusado ALEF DA SILVA NASCIMENTO teve sua revelia declarada.

O conjunto probatório é robusto para confirmar a traficância praticada pelo réu. Os laudos toxicológicos de fls. 154/156 e 157/159 confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

Os depoimentos dos guardas municipais ouvidos em juízo confirmaram que o réu estava em conhecido ponto de drogas do município de Cajamar.

O auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) corroborou o depoimento dos guardas municipais que confirmaram que no momento da abordagem foram apreendidas as drogas com o réu.

Observe que o fato de serem guardas municipais e terem atuado na diligência não os descredencia para prestar depoimento em Juízo, tratando-se de depoimentos acerca de fatos praticados no estrito cumprimento de dever legal.

Ademais, foram devidamente compromissados e não foi comprovada nenhuma inimizade com o réu, destacando-se que o réu não era conhecido deles.

Outrossim, o fato de o acusado ser usuário de entorpecente não afasta a possibilidade do delito de traficância.

Pelo contrário, não é raro que usuários passem também a comercializar entorpecentes

justamente para garantir o próprio vício, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJSP 101/498). Ademais, como também reconhecem os tribunais: "Não cabe a desclassificação do delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, para o delito de uso indevido, quando ausente a prova, a cargo da defesa, da exclusividade do uso próprio" (RT 710/325).

Assim, tratando-se de versão escusatória, cabia ao réu e à Defesa a sua demonstração de forma cabal e inequívoca, o que não fora feito nestes autos. Dessa forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em cheque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Entretanto, afasto a majorante prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, pois, ainda que não haja dúvidas de que a casa em que o réu efetuou a traficância em local próximo às instituições descritas, não é possível extrair que a traficância praticada pelo réu visasse os frequentadores dos templos religiosos ou os alunos da escola de ensino fundamental.

Dessarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, apesar de tecnicamente primário, o comércio de substância altamente letal ao ser humano (crack) impõe uma elevação nas penas bases, no montante de 1/8, resultando-se em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 562 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, encontram-se presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, vez que o acusado, à época dos fatos, contava com 20 anos (fls. 12), motivo pelos qual retorno às penas anteriormente fixadas ao patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase de cálculo penal, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o acusado é primário, portador de bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

No entanto, para evitar bis in idem deixo de valorar a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos. Nesse aspecto: "Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Luiz Fux e Marco Aurélio." (Brasília - residência -, 1º de abril de 2014. Ministro MARCO AURÉLIO).

Desta feita, aplico o redutor no patamar de 1/2, totalizando 02 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 291 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Tendo em vista que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas.

Em atenção aos artigos 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Nesse ponto, ressalto recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o tráfico de drogas, na forma privilegiada não possui natureza hedionda:

"Ementa: Habeas Corpus. Constitucional, penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Aplicação da Lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida." (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, verifico que o regime inicial aberto se mostra mais adequado, em razão da quantidade de pena aplicada ao réu, da primariedade e conduta social e personalidade favoráveis, não obstante a alta lesividade da substância entorpecente apreendida.

Deixo de aplicar o disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 12.736/12, por se tratar de hipótese de progressão de pena que, pelo nosso ordenamento jurídico, requer a análise cumulativa do requisito subjetivo, o que não é possível neste momento processual.

Por não ser medida socialmente recomendável, nego ao réu a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para CONDENAR ALEF DA SILVA NASCIMENTO, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 02 anos e 11 meses de reclusão e pagamento de 291 dias-multa em regime inicial aberto, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas.

Recurso em liberdade, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas.

Condeno o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPD.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento definitiva;

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos valores monetários e bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06;

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que, após o trânsito em julgado, também deverá ser incinerada;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido, expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminha-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se e Intime-se.

Cajamar, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA